

1500303-98.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... não possui nenhuma condenação por tráfico (fls. 142/146).

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga

Foro de Pirassununga

3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Pirassununga-SP - cep 13631-903

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500303-98.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-98.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante,

Boletim de Ocorrência - 2254782/2021 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 810/2021 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 2254782 - DEL.POL.PIRASSUNUNGA, 810/21/808 -

DEL.POL.PIRASSUNUNGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO CARDOSO DA PAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jorge Corte Júnior

Vistos.

LEANDRO CARDOSO DA PAZ e NAYARA CIRINO MANIACALES foram denunciados (fls. 129/130), como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 17h00min, nesta cidade e comarca de Pirassununga-SP, mantinham em depósito e guardavam, para consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em apertada síntese, narra a denúncia que denúncias anônimas e diligências investigativas realizadas pela Polícia Judiciária apuraram que os acusados praticavam tráfico de drogas, o que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão, registrado sob n. 1501126-66.2021.8.26.0457; na residência do casal, inicialmente os agentes localizaram cinco invólucros plásticos (ependorfs) com cocaína, na parte interna do imóvel, próximo ao portal; no dormitório do casal, em meio aos pertences da ré, dentro de um porta-joias, outros cinco ependorfs

idênticos foram localizados, além de outros oito, estes últimos vazios, com resquícios da mesma droga; havia, ainda, um pote plástico com a inscrição "fermento em pó", matéria comumente utilizada por traficantes para a diluição de cocaína; no total, foram apreendidas 10,1 gramas de cocaína em dez invólucros, bem como um aparelho celular que seria utilizado para a comercialização da substância ilícita.

Após regulares notificações aos réus e apresentação de defesa preliminar (fls. 166/168), foi recebida a denúncia em 09/12/2021 (fls. 195/196).

Durante a instrução (fls. 217), em 11/01/2022, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação e foram interrogados os réus. Em debates orais, a acusação pleiteou a procedência da ação nos termos da denúncia, tendo a defesa pleiteado a absolvição.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

No mérito, não há prova nos autos suficiente para a responsabilização penal dos réus pelo crime de tráfico de drogas.

Em juízo, a testemunha Domingos, policial civil que realizou a busca e apreensão na casa dos réus, confirmou a dinâmica dos fatos tal como narrado na denúncia; sustentou que o casal ficava frequentemente na frente da residência, em conversa com populares e com movimentação suspeita; a polícia judiciária suspeitava que os ora réus traficavam a mando de pessoa de nome Anderson, vulgo "Gordinho", conhecido dos meios policiais; disse que os réus negaram o tráfico, alegando ambos serem usuários; disse que no celular apreendido foi constatada uma única conversa suspeita entre o réu Leandro e pessoa de nome Sidnei Teodoro de Moraes, diálogo que versava sobre a baixa qualidade do estupefaciente fornecido pelo "Gordinho"; não foi encontrado dinheiro na casa dos réus; disse que o ato de guardar 'pinos' vazios é comportamento típico de traficantes, para reaproveitamento do invólucro; não presenciaram atos de efetiva traficância.

O réu Leandro, por sua vez, afirmou ser usuário de drogas; disse que havia adquirido doze pinos com o "Gordinho", que tem um bar em frente à sua casa; os pinos próximos ao portão eram para uso futuro, e aqueles dentro do quarto eram para consumo imediato; confirmou o teor do diálogo com Sidnei; disse que a fala "por isso que tá fraco o movimento" era uma referência ao movimento da 'biqueira' do "Gordinho"; disse que a movimentação de pessoas em frente à sua casa era em sua maioria por conta do bar da frente, sendo que os populares que por lá passavam por vezes paravam para conversar com eles, pois se conheciam.

Nayara confirmou a mesma narrativa; disse que seu marido Leandro é viciado em cocaína; compra drogas quase diariamente; compram cocaína com o "Gordinho"; a quantidade de cocaína que tinha em sua residência seria consumida integralmente naquele dia; Leandro chega a consumir até trinta 'pinos' de uma só vez; sobre o fermento em pó em seu quarto, sustentou que sua dispensa fica dentro de seu quarto, sendo que no local havia diversos outros itens como arroz, feijão, óleo de cozinha, etc, tendo inclusive mostrado o local pela câmera de seu celular.

Pois bem.

Não foram encontrados, com os réus, quaisquer materiais típicos do tráfico: balança, plástico filme, dinheiro, anotações, etc.

A quantidade encontrada também é bastante diminuta (cerca de dez gramas) e bastante condizente com o consumo dos próprios réus.

Ademais, a única conversa "degravada" do celular apreendido denota, a meu sentir, nada mais que trivial diálogo entre dois usuários que consomem estupefacientes do mesmo fornecedor.

Mesmo “monitorados” por alguns dias pela polícia, durante investigações, o próprio investigador afirmou que não visualizaram nenhum ato de efetiva e cabal mercancia de ilícitos.

É bem verdade que a materialidade delitiva está bem evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 37/41), auto de apreensão (fls. 44/45), auto de constatação (fls. 46/47) e laudos periciais (fls. 160/162 e 163/165).

Lembro, ainda, que os réus confessaram a posse do narcótico.

Respeitado o posicionamento final do Ministério Público, não vislumbro elementos suficientes que comprovem, de maneira indene de dúvidas, que os réus pratiquem a mercancia da droga, sendo que nem mesmo a quantidade de droga apreendida, pequeníssima, caminha nesse sentido.

É de se ressaltar, ainda, que Nayara é primária (fls. 147) e Leandro, embora com recorrente envolvimento em delitos, não possui nenhuma condenação por tráfico (fls. 142/146).

Segundo entendimento dominante na jurisprudência, a traficância não pode ser presumida. Deve ser embasada em elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado estar efetivamente praticando o comércio ilegal. Ninguém pode ser condenado por tráfico por mera suposição ou aparência. Em hipótese de dúvida deve haver desclassificação para o delito de porte de entorpecente ou absolvição conforme o caso. Já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da matéria o seguinte:

“ENTORPECENTE - Tráfico Desclassificação para o uso próprio Admissibilidade Elevada quantidade de droga apreendida que não pressupõe a certeza do comércio nefando aplicação do princípio in dubio pro reo” - RT 841/520.

“ENTORPECENTE Tráfico Desclassificação para o uso próprio Admissibilidade Pequena quantidade de droga apreendida Meras denúncias anônimas que não são suficientes para vincular o acusado à mercancia ilegal Inteligência do art.16 da Lei 6368/76” RT 842/527.

Desta forma, restou apenas a certeza de que o increpado estava com drogas, mas como dito acima em pequena quantidade e, de forma isolada, sem aptidão para configurar o delito imputado. Importante lembrar que em direito penal, em caso de dúvida, ela deve ser resolvida em favor do acusado.

Assim, a rigor, deveria haver desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.

Todavia, com relação ao delito acima indicado, teço algumas considerações.

Muitas são as polêmicas acerca do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, tantas que a Colenda 6ª Câmara Direito Criminal, do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em Acórdão da lavra do Desembargador JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES TORRES, considerou-o inconstitucional. Confira-se:

O artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é inconstitucional. A criminalização primária do porte de entorpecentes para uso próprio é de indistigável insustentabilidade jurídico-penal, porque não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por

tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil. (TJSP - Apelação Criminal nº 01113563.3/0-0000-000, 6ª Câmara Dir. Criminal, j. 31/03/2008).

Da brilhante fundamentação do v. Acórdão extrai-se:

Assim, transformar aquele que tem a droga apenas e tão-somente para uso próprio em agente causador de perigo à incolumidade pública, como se fosse um potencial traficante, implica frontal violação do princípio da ofensividade, dogma garantista previsto no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, Além disso, a criminalização do porte para uso próprio também viola o princípio constitucional da igualdade, pois há flagrante "distinção de tratamento penal (drogas ilícitas) e não-penal (drogas lícitas) para usuários de diferentes substâncias, tendo ambas potencialidade de determinar dependência física e psíquica" (Salo de Carvalho, A política criminal de drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático, Editora Lumen Juris, RJ, 2007, p. 253).

Data máxima vênia à Colenda 6ª Câmara Direito Criminal, não me animo, confesso, a uma decisão de tamanha envergadura. Creio que é suficiente para resolver a questão, por outro prisma, a aferição da periculosidade ou ofensividade da conduta e seu desvalor social. Como inúmeras vezes já enfatizei, estou convicto acerca da ausência de lesividade da conduta em casos tais, pois, segundo me parece, a conduta do consumo de entorpecentes não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica.

Destaco à luz do princípio da insignificância os seguintes julgados:

"Entorpecente. Quantidade ínfima. Atipicidade. O crime, além da conduta, reclama um resultado no sentido de causar dano ou perigo ao bem jurídico (...); a quantidade ínfima informada na denúncia não projeta o perigo reclamado". 1 Sempre "é importante demonstrar-se que a substância tinha a possibilidade para afetar ao bem jurídico tutelado". A pena deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Quando a conduta não seja reprovável, sempre e quando a pena não seja necessária, o juiz pode deixar de aplicar dita pena. O Direito penal moderno não é um puro raciocínio de lógica formal. É necessário considerar o sentido humanístico da norma jurídica. Toda lei tem um sentido teleológico. A pena conta com utilidade" (decisão de 21.04.1998, relator LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJU de 17.08.1998, p. 96.).

"Penal. Entorpecentes. Princípio da insignificância. - sendo ínfima a pequena quantidade de droga encontrada em poder do réu, o fato não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da insignificância - habeas corpus concedido (STJ, HC 17956-SP, rel. Min. Vicente Leal).

Não bastasse a circunstância da ínfima quantidade do estupefaciente, a tornar atípica a conduta, como acima visto, penso, sobretudo tendo em vista a despenalização da figura típica, conforme o art. 28 da Lei 11.343/06, que a conduta do consumo de entorpecentes não constitui fato penalmente relevante, porque, atingindo a esfera meramente pessoal do próprio consumidor, não vulnera seriamente a ordem jurídica. Destaco a propósito o voto do Desembargador Nereu José Giacomolli, que ainda ao tempo do art. 16 da Lei 6368/76, bem enfocou a questão:

"O princípio da ofensividade ao bem jurídico, como afirma Luiz Flávio Gomes (Princípio da Ofensividade no Direito Penal, p. 25), há de ser instrumentalizado e tornado efetivo, sob pena de se ter um discurso liberal e uma aplicação autoritária do Direito Penal. Como bem ensina Carbonell Mateu (Derecho Penal: Concepto y Principios Constitucionales, 1999, p. 215-218), o princípio da ofensividade ou

lesividade exige que não haja crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, dentro de um critério valorativo que a norma comporta. Mais, num Estado Social e Democrático de Direito, a intervenção punitiva somente se justifica nas condutas transcendentais aos demais que atinjam as esferas de liberdade alheias, sendo contrário ao princípio da ofensividade o castigo de uma conduta imoral, antiética ou antiestética que não invada a liberdade alheia. Ainda, este princípio descansa na consideração do crime como um ato desvalorado, isto é, contrário à norma de valoração" (TJRS - RJTJRGs 240/74 - Rec. 70013554571 - j. 18.05.2006 - RJTJRGs 257/197 e Ap. 70008849051 - j. 26.08.2004).

Penso prudente enfatizar que já ao tempo da lei 6368/76 havia outros entendimentos jurisprudenciais no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo que consideravam atípica a conduta do porte de entorpecente:

"O legislador sanciona a aquisição, a guarda e o porte do entorpecente para uso próprio, entendendo que 'o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo porque é fator decisivo na difusão do tóxico. No entanto, a partir do momento em que a consome, lesa a si próprio e sua conduta não representa mais um perigo social' (Ap. 168.697, TACRIM). Falta lesividade e sem ela não atua o Direito Penal, pois, na lúcida observação de Claus Roxin, 'o legislador, mandatário do povo, tem sua tarefa limitada à proteção do indivíduo dos ataques dos outros e a assegurar uma vida mais livre possível e de maior bem-estar possível, e nada tem a ver com tal tarefa o tutelar moralmente cidadãos adultos contra sua vontade' (Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Trad. cast. Barcelona, 1989, p. 22)" (TJSP - Ap. - Rel. Dante Busana - JTJ 168/321).

Não bastassem tais considerações sobre a figura típica do porte do entorpecente e a autolesividade, ainda acerca do princípio da insignificância poderiam ser lembrados os seguintes julgados:

"O fato penal apurado neste processo, por sua irrelevância e escassa gravidade, não deveria ter merecido significação penal, porque não ameaçou e nem ofendeu substancialmente o bem jurídico tutelado pela lei penal. É claro que, formalmente, a conduta executada pelo sujeito ativo preencheu os elementos compositivos da norma incriminadora, o que bastaria para configurar o crime, considerado o seu conceito formal. Contudo, a ação não lesionou nem ameaçou o bem jurídico resguardado pela lei de forma que justificasse a necessidade de se invocar a proteção penal, situação que pode determinar o reconhecimento da improcedência da denúncia, nos termos da regra do art. 386, III, do CPP (atipicidade do comportamento realizado). Sob o conceito material, 'crime é um desvalor da vida social, ou seja, uma ação ou omissão que se proíbe e se procura evitar, ameaçando-a com uma pena, porque constitui ofensa (dano ou perigo) a um bem, ou a um valor da vida social' (Heleno Fragoso, Lições de Direito Penal, 13.^a ed., 1991, p. 144). Sob esse aspecto substancial ficou evidente que o comportamento não revelou ofensa ao bem jurídico protegido" (TA-CRIM-SP - Ap. 1031723-5 - Rel. Márcio Bártoli).

"A natureza fragmentária do direito penal impõe que ele só se ocupe da proteção do bem jurídico relevante e não de bagatelas, sendo causa de exclusão da tipicidade a insignificância da conduta" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Márcio Bártoli - j. 05.02.97 - RJDTCrim 35/491).

Penso oportuno destacar que o princípio da insignificância deve ser aplicado também a réus eventualmente reincidentes, ou que tenham sido condenados em sentença pendente de recurso, visto que para o acolhimento daquele princípio tem-se em conta o ínfimo desvalor social da conduta, e não propriamente as condições pessoais do sujeito ativo da infração. Vale recordar o seguinte v. aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

INSIGNIFICÂNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVI-MENTO. 1. No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância é imprescindível à distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor... 2. In casu, a res furtiva se enquadra no conceito de bagatela, pois a interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto no caso concreto. 3. Circunstâncias de caráter eminentemente pessoal, tais como reincidência e maus antecedentes, não interferem no reconhecimento do princípio da insignificância (STJ - AgRg no REsp 922863 / RS - Ministra JANE SILVA - DJe 08/09/2008).

Discorrendo sobre o art. 28, Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini sustentam que "houve descriminalização formal (acabou o caráter criminoso do fato) e, ao mesmo tempo, despenalização (evitou-se a pena de prisão para o usuário de droga). O fato (posse de droga para consumo pessoal) deixou de ser crime (formalmente) porque já não é punido com reclusão ou detenção" (art. 1º da LICP) e concluem que se trata de uma "infração penal sui generis" (GO-MES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Usuário de drogas: a polêmica sobre a natureza jurídica do art. 28 da Lei 11.343/06. Disponível em: <http://www.lfg.blog.br>. 12 mar. 2007).

Sem desconhecer decisões em sentido contrário que – mais apegadas ao aspecto da incolumidade pública (supostamente violada com a conduta do porte de entorpecentes) – afastam a aplicação do princípio da insignificância a casos tais, penso, modestamente, que a inovação trazida pelo art. 28 da Lei 11343/06 é de tamanha amplitude e de tão evidente inocuidade que no meu despretenso entendimento acredito mais sensato simplesmente deixar de aplicar o novel diploma para não lançar descrédito sobre as normas penais.

Confesso não haver encontrado na pesquisa jurisprudencial um tanto aprofundada qualquer precedente que tratasse da questão a seguir ventilada, mas atrevo-me a ponderar que a "brandura" da punição é tamanha, com "resultado imponderável" – dizes de Guilherme de Souza Nucci, in "Leis Penais e Processuais Comentadas", RT, 2ª, p. 304 – que no meu modesto entendimento a inovação legislativa pode conduzir a uma situação contraditória: se o suposto autor do fato aceitar a transação penal (Lei 9099/95) estará, nessa hipótese, obrigando-se a uma prestação pecuniária ou prestação de serviços, com a única vantagem de evitar possível reincidência em casos futuros em decorrência daquela decisão judicial; se, ao invés disso, o autor do fato recusar a transação penal e a pretensão acusatória for julgada procedente, as sanções previstas no art. 28 (se é que tais medidas constituem efetiva sanção) seriam tão brandas que poderiam tornar-se um estímulo a novos delitos da mesma natureza ou quiçá ainda mais graves.

Diante desse quadro, acredito que há um paradoxo, ainda não suficientemente enfocado pelos tribunais: do ponto de vista prático talvez seja mais vantajoso ao autor do fato ser condenado sem sanção efetiva alguma que aceitar uma transação penal. Daí porque, penso mais prudente deixar de aplicar a transação penal, tudo para que o direito penal não caia num verdadeiro ridículo.

A propósito penso conveniente ressaltar a observação de Ana Luiza Barbosa da Cunha sobre o tratamento dado pelo legislador à questão:

"Todavia, não podemos deixar de observar, por derradeiro, que, muitas vezes, o objetivo do legislador de ressocializar e reintegrar o consumidor de drogas ficará inócuo, principalmente em se tratando da aplicação do instituto despenalizador da transação penal. Isso porque o novo diploma legal traz um tratamento por demais branda em relação ao não cumprimento das penas, só podendo incidir advertência acerca da necessidade de cumprir a pena alternativa e podendo chegar à aplicação da multa, porém, é sabido dos aplicadores do direito a dificuldade em se promover uma execução em razão da necessidade de possuir patrimônio. "A nova lei de drogas e o tratamento processual dispensado ao usuário" (Disponível em: <http://www.blogdolf.com.br>, 19.julho.2007).

Ante o exposto, ressaltando que atípico, a meu ver, o fato (posse de drogas para consumo próprio), JULGO IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO os réus LEANDRO CARDOSO DA PAZ e NAYARA CIRINO MANIACALES, com fundamento no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal.

Fica autorizada a destruição de eventuais amostras guardadas para contraprova, conforme art. 72 da Lei de Drogas, assim como a restituição ao investigado de eventuais bens apreendidos no inquérito policial.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado dativo.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

P.I.C.

Pirassununga, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA